

1501237-35.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... predisposição comum de meios para o crime de associação ao tráfico de droga, impondo-se a absolvição quanto a este delito.

Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. REVALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EFEITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501237-35.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501237-35.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDER FRANCISCO LANCA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

WANDER FRANCISCO LANCA e LUCILIA DA SILVA OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 23h04min, na Rua Francisco Ovídio, 265, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, guardavam e mantinham em depósito, para futura entrega a terceiros, vinte e sete porções de cocaína, pesando 9,45g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portarem dois aparelhos celulares e R\$ 770,00.

Narra, ainda, a inicial, terem se associado, os réus, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram "Tallys Carvalho Rodrigues", na saída da empresa "Casa da Piscina", localizando-se, nas vestes, seis

porções de cocaína, ocasião na qual indicou haver adquirido o tóxico com o réu, no interior do especificado estabelecimento.

Em seguida, abordaram, os agentes, o réu Wander e, em revista pessoal, encontraram seis porções de cocaína e um aparelho celular. Por indicação de Wander, efetivaram diligências na residência dele, onde localizaram a corré Lucília na posse do dinheiro, do restante da droga e de um celular.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual se duas testemunhas comuns.

Após, foram interrogados os réus

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria apenas do tráfico, requereu a condenação dos acusados nestes termos, com absolvição quanto à associação.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus alegando, em suma, serem insuficientes as provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante o estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial, e, ao depois, ante autorização dos réus, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância dos denunciados, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICILIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.035.493/AM, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.06.2022). Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade por parte dos agentes.

Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social.

Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação aos direitos dos réus, que, espontaneamente, admitiram a prática da traficância, motivando o desfecho da diligência policial.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão acostado aos autos às fls. 24/25, que revela o encontro do entorpecente, do dinheiro e dos celulares em tela.

Ainda, no pertinente à materialidade, há o laudo de constatação de fls. 31/35 e o

laudo de exame químico toxicológico de fls. 135/137, concludentes no sentido de se tratar de cocaína, a substância achada.

Os celulares foram vistoriados (fls. 157/162).

Em ambas as manifestações, assegurou o réu Wander terem os agentes invadido o imóvel e localizado apenas uma porção de cocaína, destinada ao consumo próprio, desconhecendo a propriedade do restante do tóxico apresentado.

A ré Lucília, na fase administrativa, contou estar no dormitório, na companhia do namorado Wander, quando policiais adentraram ao local, se apossaram do dinheiro, proveniente da prática de programas sexuais, bem como do celular, não tendo sido achado entorpecentes.

Em Juízo, modificou a ré a versão apresentada, pois estaria sozinha no quarto quando da chegada de agentes, que apenas na delegacia mostraram tóxico à ela. Contam os policiais terem, em patrulhamento, abordado "Tallys Carvalho Rodrigues", na saída da empresa "Casa da Piscina", localizando-se, nas vestes, seis porções de cocaína, ocasião na qual explicou haver adquirido o tóxico no interior do especificado estabelecimento, fornecendo as características físicas e das vestes do vendedor. Continuaram no sentido de haver detido o réu Wander e, em revista pessoal, encontrado seis porções de cocaína, bem como um aparelho celular.

Relataram, ainda, que, após indicação de Wander, houve buscas na residência dele, onde se depararam com a corré Lucília na posse do dinheiro, do restante da droga e de um celular. Para tais testemunhas, ambos os réus admitiram a prática do comércio ilícito, tendo Lucília afirmado ser responsável pela guarda do dinheiro obtido com a venda de tóxico, por parte do companheiro Wander.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar os réus ou forjar os crimes. Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, guarda ou transporte, por parte de ambos.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se que não há apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues). Ainda sobre o assunto: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). Por

fim: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com os réus em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de ambos.

Por isso, tem-se a destacar estarem as provas testemunhal e técnica em perfeita harmonia, permanecendo isolada a versão dos réus quanto a não serem possuidores do tóxico apreendido, que venderiam.

Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ambos os réus posta em comércio, até porque, não contam com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

É possível que façam os réus uso do tóxico, mas a venda é certa, até para garantia do uso.

Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Contudo, não foi comprovada a associação.

Isso porque, existe dúvida quanto à existência de vínculo associativo entre os réus, com estabilidade e permanência, uma predisposição comum de meios para o crime de associação ao tráfico de droga, impondo-se a absolvição quanto a este delito.

Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALTA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO. REVALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EFEITO EXTENSIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, não só há necessidade da comprovação da estabilidade, mas também, da permanência na reunião dos sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada" (STJ, REsp 1943264/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, DJe 27/09/2021).

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- WANDER FRANCISCO LANCA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- LUCILIA DA SILVA OLIVEIRA

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, para o réu Wander, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu Wander respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido:

"(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra

necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade de entorpecentes; a personalidade criminosa de Wander, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 216/224; e o concurso de agentes, fatos a apontar maior periculosidade dos réus, indicando dedicarem-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe, para ambos, comprovação de atividade atual laborativa. Neste sentido, o RHC nº 116.926, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13, no qual se decidiu que: "a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010" (g.n.). O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno WANDER FRANCISCO LANCA, R.G. n.º 48.915.273 e LUCILIA DA SILVA OLIVEIRA, R.G. n.º 59.924.031, cada um, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o caput do art. 29 do Cód. Penal.

Absolvo os réus WANDER FRANCISCO LANCA, R.G. n.º 48.915.273 e LUCILIA DA SILVA OLIVEIRA, R.G. n.º 59.924.031, da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal. Não poderá o réu Wander apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu Wander no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

Porque aguardou a ré Lucilia, a instrução do feito em liberdade, faculto eventual apelação nessa mesma condição.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do dinheiro e dos celulares (fls. 24/25), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelos serviços prestados nestes autos.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA